

1500338-15.2021.8.26.0631

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabiola Brito do Amaral

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... em razão do seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Aliás, a certidão de antecedentes de fls. 169-171 demonstra que o acusado já foi condenado definitivamente por duas vezes - ambas pelo narcotráfico (autos nº 1500590-36.2020 e 1500205-05.2019).

A mesma certidão de antecedentes demonstra que o acusado havia deixado a prisão no mês de agosto de 2021 - isto é, estava em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

2ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo - SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500338-15.2021.8.26.0631 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500338-15.2021.8.26.0631

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONNY FERNANDO SOUZA ROMAO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra JHONNY FERNANDO SOUZA ROMAO, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e artigo 329, caput, do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos descritos na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos (fls. 79-80):

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante que, no dia 1º de novembro de 2021, durante a madrugada, na Rua Maria Roza Federice, próximo ao terminal rodoviário do Jardim Modelo, nesta cidade e Comarca de Amparo, JHONNY FERNANDO SOUZA ROMAO, qualificado a fls. 14, trazia consigo e guardava, com o fim de entrega ilícita ao consumo de terceiros, a título de venda ou de qualquer outra forma de disseminação de uso, 11 porções de 'crack', pesando 7,18g, tal como descrito no auto de exibição e apreensão a fls. 16, laudo de constatação provisória a fls. 12 e laudo químico-toxicológico a ser oportunamente juntado, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar".

O acusado foi devidamente notificado (fl. 91) e apresentou defesa preliminar (fls. 96-100). A denúncia foi formalmente recebida em 01 de fevereiro de 2022 (fls. 103-

104). No decorrer da instrução processual foi inquirida uma testemunha arrolada em comum pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público, após analisar o conjunto probatório, entendeu estarem devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnando pela sua condenação nos termos da peça exordial acusatória.

Por sua vez, em alegações finais, a defesa do acusado pleiteou a sua absolvição quanto ao crime de tráfico, sustentando que não foram produzidas provas suficientes a demonstrar a autoria delitiva. Ressaltou que o réu é usuário de entorpecentes e negou a prática criminosa em seu interrogatório, havendo dúvidas a impedir um eventual decreto condenatório. Quanto ao crime de resistência, observou que a descrição dos fatos não foi narrada na denúncia ou nas alegações finais da acusação, sendo de rigor o seu afastamento. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou a aplicação da pena no mínimo legal e a fixação de regime inicial semiaberto (fls. 176-181).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Preliminarmente, antes de adentrar a discussão do mérito, faz-se forçoso tecer esclarecimentos com relação a dois erros materiais encontrados na denúncia – um enaltecido pelo próprio Ministério Público em suas razões finais, e outro pela defesa técnica. Não são equívocos graves que demandem um formal aditamento da denúncia, mas merecem ser abordados a fim de se evitar futuros inconvenientes processuais.

O primeiro esclarecimento diz respeito ao tipo de entorpecente em tese apreendido com o réu. A denúncia afirmou que foram 11 porções de “crack”. Todavia, todas as outras peças processuais (incluindo depoimentos, laudo e fotografia) indicam que foram, na verdade, 11 porções de “cocaína”.

É certo que se trata de mero erro material e que não houve qualquer prejuízo à defesa técnica. Aliás, a diligente e atenta Defensora já havia notado o equívoco desde a sua defesa preliminar (fls. 96-100). Já em audiência, o guarda municipal enalteceu que as porções localizadas eram cocaína, e não “crack”. O réu foi indagado justamente com relação à cocaína.

Deste modo, e considerando o princípio “pas de nullité sans grief”, não verifico qualquer nulidade processual, razão pela qual aceito a correção de erro material nos termos propostos pelo Ministério Público em suas razões finais.

O segundo equívoco, por sua vez, foi abordado pela defesa técnica em seus memoriais. Verifica-se que, em sua denúncia, o Ministério Público apresentou uma formal acusação em face do réu, dando-o como incurso no tráfico de drogas (conforme se verifica pela leitura da peça, às fls. 79/80). Ocorre, todavia, que por um lapso a Dra. Promotora fez constar no último parágrafo a capitulação do crime como sendo “artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e artigo 329, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal” (fl. 80).

Significa dizer que o Ministério Público mencionou a capitulação do artigo 329 do Código Penal (crime de resistência), sem ter feito qualquer menção anterior a este delito. O equívoco (erro material) se tornou mais evidente ainda no decorrer do processo, vez que em todas as suas manifestações (incluindo alegações finais) o representante do Parquet jamais voltou a mencionar o “artigo 329”, somente tratando o caso como “tráfico de drogas”.

De fato, a doutrina entende que o réu se defende dos fatos mencionados na exordial acusatória, e não da capitulação apontada ao final. Isto é tão verdade que o próprio Legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de alterar a capitulação no momento da sentença, se entender que outra se amolda melhor aos fatos descritos (vide artigo 383 do Código de Processo Penal).

Acontece que este Juízo, ao receber a denúncia, também repetiu a menção ao “artigo 329” (conforme fls. 103-104). Porém, tal decisão deve ser parcialmente revista, a fim de rejeitar a capitulação referente ao crime de resistência, haja vista sua flagrante inépcia (artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal).

Não é demais ressaltar que esta presente decisão em nada prejudica à Defesa. Antes, pelo contrário, lhe beneficia, na medida em que afasta a possibilidade de uma

condenação por outro ilícito.

Portanto, afastada a incorreta imputação de resistência, passo a analisar o mérito somente em relação ao tráfico de drogas.

A pretensão punitiva estatal procede.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 31-34), auto de exibição e apreensão (fl. 16), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 12), fotografia das drogas (fl. 30) e, especialmente, pelo laudo químico-toxicológico (fls. 83-85).

A autoria é igualmente certa e recai sobre o acusado. Consta dos autos que JHONNY é um indivíduo bastante conhecido nos meios policiais, justamente em razão do seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Aliás, a certidão de antecedentes de fls. 169-171 demonstra que o acusado já foi condenado definitivamente por duas vezes – ambas pelo narcotráfico (autos nº 1500590-36.2020 e 1500205-05.2019).

A mesma certidão de antecedentes demonstra que o acusado havia deixado a prisão no mês de agosto de 2021 – isto é, estava em liberdade há menos de 03 meses quando voltou a ser flagrado em situação de traficância. Além disso, na data da prisão declarou que estava desempregado e residia no município de Itapira/SP (conforme fl. 13) – tudo a indicar que estava em Amparo/SP com a única finalidade de praticar o ilícito.

Pois bem. Na data dos fatos, em meio à madrugada, uma equipe da Guarda Municipal foi acionada para verificar uma ocorrência de perturbação do sossego. Enquanto se encaminhavam ao local, passaram pela praça anexa ao terminal rodoviário do Bairro São Dimas – local amplamente conhecido como “ponto de tráfico”.

Tão logo se aproximaram da praça, os agentes puderam ver o momento em que JHONNY se aproximava de um veículo estacionado, como quem pretende entregar algo. Todavia, ao perceber a movimentação da viatura, o réu se virou bruscamente e passou a caminhar em direção oposta ao carro. O motorista, por sua vez, empreendeu fuga em alta velocidade.

É evidente que a postura do acusado chamou a atenção da guarnição, em especial pelo local e pelo horário. Deste modo, optaram por realizar uma abordagem. JHONNY se mostrou bastante agitado e agressivo, de modo que precisou ser algemado. Em busca pessoal, guardas localizaram em seu poder cinco papелotes de cocaína e a quantia de R\$ 87,00 em notas diversas.

Em prosseguimento, a equipe efetuou buscas pelas imediações e, ao conferirem uma pilha de tijolos (localizada bem próxima ao local da abordagem), vieram a encontrar outros seis papелotes da mesma droga. Importante destacar que todas as 11 porções estavam embaladas de maneira idêntica e já prontas para a venda (conforme fotografia de fl. 30).

Diego Aparecido Tonelotto Catiollo, guarda municipal, prestou depoimento em Juízo e confirmou os fatos conforme narrados acima. Relatou que, na ocasião, foram acionados para atender a uma ocorrência versando sobre “perturbação de sossego”. Chegando ao local, puderam avistar o réu caminhando em direção a um veículo, de maneira bastante suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, o JHONNY se virou e caminhou para a direção contrária, ao passo que o motorista do veículo se evadiu. Diego explicou que aquele local é bastante utilizado na prática do tráfico, motivo pelo qual decidiram promover a abordagem. Em um primeiro momento, o JHONNY resistiu e entrou em luta corporal com a equipe. Após ser imobilizado, o réu foi revistado e trazia R\$ 87,00 e cinco porções de cocaína. Em ato contínuo, fizeram uma busca rápida pelas imediações e localizaram outras seis porções idênticas àquelas apreendidas com o acusado. Ele foi indagado de maneira informal e acabou admitindo o tráfico, dizendo que vendia as porções para conseguir sustentar o próprio uso da droga.

Ressalte-se que Marcos Roberto de Godoy, o outro guarda municipal presente na ocorrência, prestou depoimento na fase inquisitiva (fl. 04) e corroborou todo o contexto narrado pelo seu colega. Inclusive, confirmou que JHONNY chegou a confessar os fatos informalmente à equipe.

Todavia, não obstante a clareza das provas, JHONNY optou por negar o crime em Juízo. Alegou que é “usuário crônico” de cocaína e que, na ocasião, trazia apenas

duas porções da droga em seu bolso, as quais se destinavam ao seu consumo pessoal. Alegou que estava no local “esperando” para ver se sua tia iria passar, pois ela reside ali perto. Os guardas municipais já desceram da viatura promovendo agressões. Em seguida, eles encontraram drogas na praça e imputaram a ele de forma injusta.

Referida versão, evidentemente, não encontra qualquer suporte no contexto fático-probatório constante dos autos. Com efeito, não parece minimamente plausível que os guardas municipais tenham escolhido alguém de maneira aleatória para acusar de um crime tão grave – ainda mais alguém que eles não conheciam.

Em verdade, a narrativa de JHONNY se mostrou deveras fantasiosa. Segundo o boletim de ocorrência (fls. 31-34), os fatos ocorreram por volta das 02h00min da madrugada, não sendo razoável que o réu estivesse ali “esperando para ver se sua tia iria passar”. Ressalte-se que JHONNY residia em outro município, conforme indicado por ele próprio na Delegacia.

Ademais, o réu demonstrou não ser confiável. Por exemplo: apesar de já possuir duas condenações criminais transitadas em julgado, ambas pelo narcotráfico (fls. 169-171), e muito embora já tenha ficado preso por um dos processos anteriores, insistiu em afirmar que jamais foi processado pelo tráfico de drogas.

JHONNY também não foi capaz de justificar o porquê os guardas municipais estariam acusando-o de maneira injusta e gratuita. A verdade é que, diferentemente do que tenta sustentar a defesa, as narrativas dos agentes policiais se mostraram claras e coerentes entre si, não havendo qualquer razão a diminuir a sua credibilidade.

Sobre o tema, há entendimento solidificado nos Tribunais Superiores:

“Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ – HC 408808/PE, 5ª T., rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 03.10.2017).

E ainda:

“É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ – HC 393516/MG, 5ª T., rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.06.2017).

Assim, verifica-se, que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu praticou o crime de tráfico de entorpecentes, conforme narrado na denúncia. Isso decorre a partir da análise e da valoração dos elementos colhidos na instrução, especialmente as declarações consistentes e seguras prestadas pelos agentes que participaram da ocorrência.

Ante o exposto: a) REVOGO parcialmente a decisão de fls. 103-104 e, como consequência, REJEITO a denúncia relativa ao crime previsto no artigo 329, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal; e b) JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia para CONDENAR JHONNY FERNANDO SOUZA ROMAO, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Em razão disso, passo a dosar a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do Código Penal. Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada havendo a se valorar. Porém, verifico que JHONNY já foi condenado por duas vezes em crimes análogos ao do presente feito (conforme autos nº 1500590-36.2020 e 1500205-05.2019 – fls. 169-171). Tanto o Ministério Público como a defesa técnica concordaram que tais condenações não podem ser havidas a título de reincidência. De fato, o artigo 63 do Código Penal dispõe que a reincidência só ocorre quando o novo crime se dá após o trânsito em julgado da condenação anterior. Por outro lado, nada impede que tais condenações sejam utilizadas para valorar os maus antecedentes do acusado, nos termos do que costumam decidir os Tribunais Superiores:

“O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência,

abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada a casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (HC 511046/SP, 6ª T., rel. Ministra Laurita Vaz, j. 18.08.2020).

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, e tendo em vista a existência dos péssimos antecedentes criminais, é que fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, vez que o acusado era menor de 21 anos na data dos fatos. Em razão disso, atenuo sua reprimenda em 1/6 (um sexto).

Inexistem circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição ou de aumento. Vale enaltecer a impossibilidade da concessão ao réu do benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Para que tal figura privilegiada seja reconhecida, devem ser preenchidos alguns requisitos objetivos e subjetivos previstos pela própria Lei, como por exemplo a condição de que o acusado não possua maus antecedentes e nem se dedique a atividades criminosas.

No caso dos autos, existem fortes elementos a indicar que JHONNY se dedicava constantemente ao ramo ilícito do tráfico. O acusado foi preso menos de três meses após sua soltura anterior, estando em cidade diversa da que reside. Além disso, estava desempregado no momento do flagrante, não havendo justificativa para posse das porções ilícitas.

Ademais, conforme já indicado, o réu ostenta duas condenações definitivas pelo crime de narcotráfico (fls. 169-171), o que, por si só, impede a concessão do benefício. Vale ressaltar que nas duas condenações anteriores JHONNY já havia sido beneficiado com o "tráfico privilegiado" – o que acabou por se mostrar ineficaz para prevenir novos atos criminosos.

Assim, torno definitiva a pena do réu em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.

Em face do que dispõe o artigo 2º, §1º da Lei 8.072/90, e levando em consideração os maus antecedentes e a grande e comprovada incidência do tráfico de entorpecentes nesta Comarca, que vêm causando incontáveis e irrecuperáveis estragos, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, uma vez que não estão presentes os requisitos legais, sobretudo em face da hediondez do ato praticado. Além disso, é bastante evidente que a aplicação de qualquer destes benefícios não se mostraria suficiente para a alta reprovação social que o tráfico de drogas encontra, especialmente nesta Comarca.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permanecem incólumes os motivos que ensejaram a manutenção da custódia cautelar. Vale ressaltar que as provas indicam que o crime vinha sendo promovido de maneira reiterada, de forma que o réu vinha fazendo do tráfico o seu meio de vida. É evidente que tais condutas, associadas aos maus antecedentes do réu, não aconselham a concessão de liberdade provisória neste momento, haja vista a necessidade de se garantir a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra detido.

Expeça-se a devida certidão de honorários à Patrona nomeada por meio do convênio DPE/OAB, na proporção dos serviços prestados (fl. 93).

Quanto ao numerário apreendido (R\$ 87,00), tendo em vista ser fruto do tráfico, determino o seu perdimento em favor da União, devendo a serventia providenciar a necessária transferência à SENAD após o trânsito em julgado da condenação. O comprovante de depósito do valor encontra-se juntado à fl. 72.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Expeça-se a guia de execução do réu.

2) Em cumprimento ao disposto no artigo 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua

devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do contido no artigo 15, III, da Constituição Federal.

3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

4) Oficie-se à SENAD, nos termos do artigo 63, §4º, da Lei 11.343/06.

Custas na forma da Lei.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Amparo, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA